

1503557-61.2021.8.26.0073

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: LEONARDO LABRIOLA FERREIRA MENINO

Comarca: Avaré

Foro: Foro de Avaré

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/04/2022

... Justiça de São Paulo:

"Apelação Criminal -Tráfico de entorpecente- Nulidade do processo e da prova coligida porque a busca domiciliar fez-se sem autorização judicial -Inexistência Tráfico de entorpecente na modalidade "ter em depósito" é crime permanente - A ocorrência de flagrante delito justifica a busca domiciliar sem autorização judicial -Tipificação- A prova oral, a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Avaré

Foro de Avaré

1ª Vara Criminal

Rua Abílio Garcia, 527, Avare-SP - cep 18706-047

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1503557-61.2021.8.26.0073 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503557-61.2021.8.26.0073

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial - 2226572/2021 - DEL.SEC.AVARE PLANTÃO, 19739342 - DEL.SEC.AVARE PLANTÃO, 2333/21/129 - DEL.SEC.AVARE PLANTÃO, 2226572 - DEL.SEC.AVARE PLANTÃO, 2226572 - DISE- DEL.SEC.AVARE, 2333/21/129 - DISE- DEL.SEC.AVARE, 068/2021 - DISE - Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes de Avaré

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ELCIO BENEDITO DA SILVA JUNIOR e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LEONARDO LABRIOLA FERREIRA MENINO

VISTOS.

ELCIO BENEDITO DA SILVA JÚNIOR e JOÃO DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE NETO, já qualificados nos autos, foram denunciados pelo Ministério Público como incursos nas sanções dos artigos 33, "caput", da Lei 11.343/06, sob a acusação de que, transportaram e venderam 15 (quinze) tijolos de maconha, com peso aproximado de 16.011,36 (dezesesseis mil, e onze gramas e trinta e seis centigramas) e 01 (uma) porção de cocaína, com peso de 53,77g (cinquenta e três gramas e setenta e sete centigramas), conforme laudo de constatação provisória a fls. 60/63, substância que causa dependência, o que fazia em desacordo com norma legal ou regulamentar (portaria 344/98 SVS/MS). BRUNO JOSÉ RIBEIRO BARBOSA, já qualificado, foi denunciado como incurso nas sanções do art. 33, § 1º, inciso III, da lei 11.343/06 porque, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar acima mencionadas, neste município e Comarca de Avaré, consentiu que o denunciado ELCIO utilizasse de sua residência, mediante contraprestação, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para o tráfico ilícito de drogas.

Auto de prisão em flagrante e demais peças do inquérito policial a fls. 01/201. Por ocasião da apreciação da prisão em flagrante houve a decretação da prisão preventiva (fls. 102/105). Mandados de prisão cumpridos a fls. 182/193. A denúncia foi oferecida em 01 de setembro de 2021 e os réus, devidamente notificados (fls. 252/253 e 255), apresentaram Defesa Prévia (256/265, 272 e 327/333). Não sendo o caso de absolvição sumária, a denúncia foi recebida em 12 de janeiro de 2022, ocasião em também foi designada audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento (fls. 357/362). Em audiência, foram inquiridas 02 testemunhas de acusação, 03 testemunhas de defesa e os réus interrogados (fls. 464/465 e gravações audiovisuais).

Em sede de alegações finais, o Ministério Público postulou pela condenação dos réus nos exatos termos da denúncia (fls. 469/474). A Defesa do réu João de Oliveira pugnou pela absolvição com fundamento o artigo 386, incisos VI e VII, do CPP. Subsidiariamente, em caso de condenação, pugnou pela fixação da pena em seu patamar mínimo legal, pela aplicação da minorante do § 4º do art. 33 e substituição da pena privativa por restritiva de direitos (fls. 475/487). A Defesa do corréu Elcio Benedito da Silva Júnior, preliminarmente, pleiteou pelo reconhecimento da nulidade da prova em decorrência da ausência de mandado de busca domiciliar. No mérito, pleiteou pela absolvição com fundamento no artigo 386, inciso VII, do CPP. Subsidiariamente, em caso de condenação, requereu a fixação da pena em seu patamar mínimo legal, pelo reconhecimento da atenuante da confissão, pela aplicação do privilégio do § 4º, bem como pelo direito de recorrer em liberdade (fls. 488/496). A Defesa do réu Bruno José pleiteou pela absolvição com fundamento no artigo 386, inciso VI, do CPP e, subsidiariamente, em caso de condenação, pela fixação da pena em seu patamar mínimo legal, pela aplicação do privilégio, pela fixação do regime inicial aberto e substituição por pena restritiva de direitos (fls. 503/510). É, sucinto o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Segundo a inicial acusatória, "na data dos fatos o denunciado JOÃO, utilizando o veículo VW/Gol Sportline 1.6, placas EPD5A66, transportou do município de Marília/SP para Avaré/SP, quinze tijolos de maconha e uma porção da cocaína, drogas adquiridas pelo denunciado ELCIO, certo que JOÃO receberia pelo transporte o valor de mil reais. A fim de concluir a venda ilícita, ELCIO ajustou com BRUNO a utilização de sua residência, mediante a contraprestação de cem reais, para que pudesse pesar as drogas adquiridas, com o que o denunciado consentiu. Ocorre que no momento da entrega das drogas na via pública, ELCIO e JOÃO foram surpreendidos pela Polícia Militar, empreenderam fuga ao imóvel de BRUNO, resultando na perseguição e prisão de todos pelos agentes estatais. Foram apreendidos, ainda, um telefone celular e a quantia de R\$ 504,00 (quinhentos e quatro) reais em espécie e notas diversas. A quantidade de droga apreendida, sua forma de acondicionamento e as circunstâncias da prisão indicam que os entorpecentes se destinavam ao fornecimento e entrega ao consumo de terceiro".

De prêmio, a preliminar de nulidade de provas alegada pela Defesa do réu Elcio não merece prosperar. A entrada dos policiais na residência não ocorreu de forma

irregular, tampouco o flagrante foi ilegal não havendo, pois, se falar em irregularidade e/ou nulidade.

Ora, o ingresso dos policiais na residência do corréu Bruno sem autorização judicial, não está eivado por qualquer mácula. Primeiramente, porque não há comprovação de que a entrada não foi permitida. De fato, não há qualquer menção nos autos de resistência ao ingresso dos agentes por parte dos residentes.

Em adição, o artigo 5º, XI, da Constituição Federal prevê que a busca domiciliar não prescinde de mandado judicial, salvo nas hipóteses excepcionais, constitucionalmente previstas, dentre elas o caso de flagrante delito. Como é cediço, o ato análogo ao tráfico de entorpecentes é crime permanente e, em caso de flagrante de crime dessa natureza é possível a realização de busca domiciliar sem mandado judicial.

Assim, era perfeitamente lícito aos policiais, incumbidos do combate à criminalidade, adentrar na casa onde a droga estava sendo fracionada. Não se pode cogitar, por conseguinte, na ilicitude das provas obtidas, pois o momento consumativo do delito de traficância se prolonga no tempo. A respeito da prescindibilidade do mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante de crime permanente, há sedimentada jurisprudência do E. Supremo Tribunal Federal: "A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados" (RE nº 603.616/TO; Relator Ministro Gilmar Mendes). Nesse sentido, já se posicionou o Tribunal de Justiça de São Paulo:

"Apelação Criminal -Tráfico de entorpecente- Nulidade do processo e da prova coligida porque a busca domiciliar fez-se sem autorização judicial -Inexistência Tráfico de entorpecente na modalidade "ter em depósito" é crime permanente - A ocorrência de flagrante delito justifica a busca domiciliar sem autorização judicial -Tipificação- A prova oral, a quantidade e a variedade de forma do entorpecente apreendido em poder dos réus asseguram que a droga se destinava à venda . Consumação .Para a consumação do crime do artigo 33 da Lei n.º 11.343/06, de ação múltipla, é desnecessário surpreender o agente em ato de mercancia, bastando que haja conduta que se ajuste a um dos verbos do tipo penal (misto alternativo Ausência de elementos seguros a indicar que os acusados estivessem associados para traficar Liame subjetivo de caráter estável não caracterizado Recursos desprovidos" (Apelação Criminal n.º 990.08.160355-1 rel. Desembargador José Raul Gavião de Almeida) (g.n.).

Ora, finda a instrução processual, restou claro que a abordagem foi motivada pela suspeita de traficância.

Inquestionável que a ação dos agentes da lei se revestiu de fundada suspeita, em conformidade com o artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal, sendo descabida a aventada ilegalidade da busca pessoal.

No mérito, ao ver deste Juízo, a ação penal merece ser julgada parcialmente procedente.

A materialidade delitativa está consubstanciada no auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), boletim de ocorrência (fls. 03/08), no auto de exibição e apreensão de fls. 47/48, fotografias de fls. 54/59, laudo de constatação provisória a fls. 60/63, laudo de exame químico-toxicológico a fls. 151/156, bem como por toda prova oral produzida em juízo.

A autoria, de igual modo, restou incontestada apenas em relação aos réus Elcio Benedito e João de Oliveira.

O policial militar Paulo Augusto de Souza, em juízo, contou "que estavam em patrulhamento de rotina quando avistaram um carro suspeito e decidiram abordá-lo. Disse que os réus Elcio e João ao avistarem a viatura empreenderam fuga . Contou que Elcio foi abordado cerca de 100 metros da casa do corréu Bruno e João no quintal da referida residência. Disse que em frente da casa do réu Bruno apreenderam as drogas as quais estavam acondicionadas em um saco preto".

A testemunha de acusação Fabricio Maisse, policial militar, judicialmente, reprisou

a assertiva de seu colega. Acrescentou "que após a abordagem questionaram os réus sobre a droga apreendida e que João admitiu que veio de Marília transportando a droga e que receberia R\$ 1.000,00. corroborou a versão da testemunha. Falou que Elcio alegou ter emprestado a casa de Bruno pela quantia de R\$ 100,00".

As testemunhas de defesa Débora Furtado e Paulo Roberto de Oliveira Almeida, em juízo, contaram "que Elcio sempre teve ocupação lícita, trabalhando em uma fábrica de churrasqueira e que o réu nunca precisou se envolver com o tráfico de entorpecentes e que nunca ouviram boatos nesse sentido".

A testemunha de defesa Fabio Barbosa de Lima, sob o crivo do contraditório, "disse que conhece o réu João há muito anos e que é trabalhador e honesto. Disse que nunca soube do seu envolvimento com drogas e contou que, dias antes do crime, tinha um rapaz recrutando um motorista para levar uma "muamba" para a cidade de Avaré e estaria pagando pela empreitada a quantia de R\$1.000,00."

O réu Elcio Benedito, em seu interrogatório judicial, confessou a prática dos fatos que lhe são imputados na denúncia afirmando que "que a droga seria entregue a outra pessoa".

O réu João de Oliveira, em seu interrogatório judicial, disse "que foi contratado para o transporte pelo valor de R\$ 1000,00, mas que não sabia que estaria transportando drogas no veículo".

Por fim, o réu Bruno José, disse "que não sabia que o réu Elcio estaria com drogas, pois ele alegou que levaria uma mulher para o interior da sua residência para manterem um possível relacionamento".

Com efeito, diante das provas colhidas em juízo, a absolvição do réu Bruno José é medida que se impõe, vez que a prova colhida em juízo não apontou que o réu comercializava entorpecente. Ora, ainda que plausível, em tese, a versão inicialmente dada pela Acusação, deve prevalecer a presunção de inocência que milita em favor da parte ré quando o Estado não prova, estreme de dúvida, o fato criminoso imputado na ação penal.

No caso dos autos, malgrado a existência de indícios, é forçoso reconhecer que o conjunto probatório angariado não autoriza a prolação de édito condenatório. Assim, havendo dúvidas deve prevalecer o princípio "in dubio pro reo". Como se sabe, a avaliação da prova, no juízo criminal, pode levar o julgador à certeza ou à dúvida quanto à autoria de um delito. A certeza que se exige para uma condenação é a persuasão produzida no ânimo do juiz, de acordo com a normalidade de agir das pessoas, de forma a excluir qualquer dúvida prudente. Não significa a inexistência de entrelanços de provas ou de conflito de elementos, mas sim que um deles, racional e cientificamente, não merece consideração, devendo ser desprezado.

Por outro lado, feito o exame, ponderadas as provas, encontrados motivos concludentes e persuasivos alicerçando as afirmações antagônicas feitas pelas partes, sem que o julgador possa afirmar qual a verdadeira, tem-se a dúvida e, com ela, a obrigatoriedade da absolvição, pois milita a favor da parte acionada criminalmente uma presunção relativa de inocência. Analisando a recente alteração do art. 155 do Código de Processo Penal, leciona Guilherme de Souza Nucci que:

"a nova disciplina do controle de apreciação da prova integra o sistema da persuasão racional, pois continua a permitir ao magistrado que forme a sua convicção livremente, analisando o conjunto probatório, desde que o faça motivadamente e calcado nos parâmetros constitucionais acerca dos limites ideais para a produção de prova. Esses limites são traçados pelo princípio do contraditório e ampla defesa (...) a meta é a formação da convicção judicial baseada em provas produzidas sob o crivo do contraditório, mormente não podendo o magistrado fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos trazidos da investigação a policial, que constitui a maior parte dos procedimentos preparatórios da ação penal."

Assim sendo, os elementos de convicção carreados aos autos mostram-se aptos a instaurar a dúvida no espírito do julgador, fazendo com que se prolate um decreto absolutório. Não é demais lembrar que:

"em matéria de condenação criminal, não bastam meros indícios. A prova da autoria deve ser concludente e estreme de dúvida, pois só a certeza autoriza condenação no juízo criminal. Não havendo provas suficientes, a absolvição do réu deve

prevalecer" (In RT. 708/339)" (g.n.)

Isto posto, parece-nos temerário condenar o réu Bruno José na medida em que se tornou bastante frágil a vinculação dele ao crime em questão.

Diversamente, o crime de tráfico de drogas praticado pelos réus Elcio Benedito e João de Oliveira restou cabalmente comprovado. A confissão dada pelos réus, ainda que parcial do corréu João, representa dado relevantíssimo na formação da convicção, máxime se valorizado seu poder de convencimento pelo restante da prova colhida tal como se verifica no presente caso, nada existindo no sentido de infirmá-la ou fragilizá-la.

Assim, as provas colhidas em juízo apontam para a ilícita mercancia praticada pelos acusados. A tipificação do crime de tráfico de drogas, in casu, extrai-se das circunstâncias da prisão, da quantidade de droga apreendida (15 tijolos de maconha pesando mais de 16 kg e 01 porção de cocaína pesando mais de 53 gramas), do modo pelo qual estava acondicionada, bem como localização de dinheiro, cuja origem lícita os réus não comprovaram.

Nesse passo, cabe ressaltar que o depoimento prestado pelos policiais é, em essência, coerente e harmônico com as provas acostadas aos autos, bem como com as versões prestadas pelos réus em seus interrogatórios, que caminhou no mesmo sentido do alegado pelos policiais. É de se asseverar que o simples fato da testemunha ouvida ser policial nada significa para que seja desconsiderado seu depoimento ou que este seja recebido com reservas. Imprescindível salientar que é entendimento pacífico em nossa jurisprudência que os depoimentos de policiais ou agentes públicos em geral, apenas pela sua condição, não podem ser desconsiderados ou desacreditados, em primeiro lugar porque, constitucionalmente, são eles aptos, como qualquer cidadão, a presar testemunho sob o compromisso da lei. De outra forma, seria incoerente negar a quem tem por função salvaguardar a ordem pública o direito (e o dever) de prestar contas de sua função, justamente quando a cumpre a contento. A desconsideração de depoimento somente procede quando decorrente de atos de parcialidade, motivados por vingança ou perseguição e desde que comprovados de forma segura e objetiva, o que efetivamente não se evidenciou nestes autos. Ressalte-se, por fim, que a diligência policial a qual culminou com a apreensão do entorpecente, somente ocorreu devido à divergência constante na cor do veículo descrita no documento. Confira-se:

"PROVA - Testemunha - Policial Militar - Validade - Reconhecimento -

Impossibilidade de invalidar o depoimento de Policial Militar, por suspeito ou impedido de depor, só porque ostenta essa qualidade, uma vez que, seria incurial, um verdadeiro contrassenso, o Estado credenciar alguém como seu agente e, ao depois, quando este prestasse conta de suas diligências, fosse taxado de suspeito - Recurso improvido." (Apelação Criminal n. J. 103.338-3/6 - São Paulo 9º Câmara Criminal - Relator: Ubiratan de Arruda - 30.1.2008-V.U.)

Considere-se ainda que, em casos de crimes graves, como o tráfico de entorpecentes, a grande maioria das pessoas evita servir como testemunha, imperando verdadeira lei do silêncio, razão pela qual desprezar os depoimentos policiais nesses casos implicaria consagrar a total impunidade.

Ressalto, ainda, que para caracterização do crime de tráfico de drogas não é indispensável que o agente seja flagrado realizando o comércio de drogas. O tipo penal do art. 33, "caput", da Lei n. 11.343/2006 é de conteúdo múltiplo e define crime de perigo abstrato. Dessa maneira, basta a conduta de "guardar, ter em depósito, transportar", desde que evidenciada a finalidade de entrega a terceiro, para que o crime em questão reste caracterizado. E, no caso, essa finalidade está bem evidenciada, eis que a quantidade de droga apreendida (15 tijolos de maconha pesando mais de 16 kg e 01 porção de cocaína pesando mais de 53 gramas) é fator considerável à caracterização do tráfico, tornando-se incabível falar em desclassificação para o crime de posse de drogas. Nesse sentido:

"... não é indispensável a prova efetiva e direta de qualquer ato de comércio clandestino de droga, bastando o conjunto de indícios e presunções que, saliente-se, são claros e convergem contra o acusado, não podendo o juiz desprezar as regras de experiência comum (praesumptiones hominis), ou seja, a ordem normal das coisas, representando aquelas o conhecimento adquirido pela prática e observação do

cotidiano." (TJSP, Apelação n. 0019906-40.2012.8.26.0071, rel. Julio Caio Farto Salles, j. 11/12/2014) (g.n.).

...

"a noção legal de tráfico de entorpecentes não supõe, necessariamente, a prática de atos onerosos ou de comercialização" (STF, 1ª T. H.C. nº 69.806/GO, Rel. Min. Celso de Mello, Diário da Justiça, Seção I, 04/06/1993, p.11.012)

Por fim, no que tange aos argumentos Defensivos, no sentido de que não há provas suficientes para a condenação, são eles precários, insubsistentes e revelam-se desamparados ante o quadro acusatório firmemente consolidado nos autos. Em verdade, a simples alegação de ausência de provas não é suficiente para afastar a responsabilidade imputada, carecendo de um mínimo qualquer de credibilidade a autodefesa, destituída que foi e é de qualquer alicerce. Ademais, não demonstrou vício no flagrante e no resultado da persecução.

Diante do exposto, por esses fundamentos e mais o que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal e, em consequência, ABSOLVO o réu BRUNO JOSÉ RIBEIRO BARBOSA, já qualificado nos autos, da imputação no tocante ao crime previsto no artigo 33, § 1º, inciso III, da Lei nº 11.343/06 com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Por outro lado, CONDENO os réus ELCIO BENEDITO DA SILVA JÚNIOR e JOÃO DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE NETO, ambos já qualificados nos autos, como incurso nas sanções do artigo 33, "caput", da lei 11.343/06. Resta dosar a pena de acordo com o critério trifásico adotado pelo Código Penal.

Vertente ao réu Elcio Benedito da Silva Júnior, na primeira fase, em observância ao artigo 42 da Lei de Drogas, bem como aos elementos preconizados pelo artigo 59 do Código Penal, verifico que, embora o réu ostente antecedentes criminais (F.A. e certidões a fls. 227/228 e 433/436), a pena base não merce exasperação vez que o acusado se manteve inerente aos moldes do tipo penal em espécie, nos exatos termos do artigo 42 da lei 11.343/06. Assim, fixo a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa. Fixo o valor do dia-multa no mínimo legal, ante a falta de elementos sobre a real situação econômica do réu (CP, arts. 49 e 60). Na segunda fase, embora presente a agravante da reincidência (fls. 227/228), o réu confessou a prática delitativa. Assim, faço a compensação e mantenho a pena no patamar anterior fixado, nos termos da Súmula/STJ, nº 545: "Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal". Não estão presentes outras agravantes ou atenuantes. Por fim, na terceira fase, entendo que inexistem causas de aumento ou de diminuição da pena. Não incide a benesse prevista no §4º do artigo 33 da Lei de Drogas, pois o réu não preenche todos os predicados legalmente previstos, pois, além da reincidência (fls. 227/228), a quantidade e variedade da droga apreendida aliado ao fato de que confessou estar guardando para terceira pessoa revelam que se dedica à atividade criminosa. Nesse sentido: "Não há ilegalidade na negativa de aplicação da causa especial de diminuição prevista no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, porquanto a quantidade e a natureza da substância apreendida levaram à conclusão de que o paciente se dedica a atividades delituosas, ou seja, não se trata de tráfico de drogas ocasional" (HC 297447/RS, Ministro JORGE MUSSI, DJe 13/11/2014). E nem se alegue possível bis in idem relativo ao aumento da pena pela reincidência e a não aplicação do aludido redutor, uma vez que este deixou de incidir também em virtude da dedicação às práticas delitivas, tudo em fases distintas da dosimetria. Confira-se: "A valoração da reincidência na segunda etapa da dosimetria, como circunstância agravante, não é incompatível com a sua utilização, na terceira fase, para afastar a incidência da causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, porquanto o referido instituto jurídico é sopesado com finalidades distintas em cada fase de fixação da pena, justamente para se alcançar a justa e correta reprimenda necessária para a reprovação e prevenção do delito perpetrado. Precedentes" (HC 214069/SP - Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ - Sexta Turma - DJe 29/11/2013). Desta forma, fixo em definitivo a pena a cumprir de 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA COM O DIA UNITÁRIO NO PISO MÍNIMO LEGAL. Em relação ao réu João de Oliveira Albuquerque Neto, na primeira fase, em

observância ao artigo 42 da Lei de Drogas, bem como aos elementos preconizados pelo artigo 59 do Código Penal, verifico que, embora o réu ostente antecedentes criminais (F.A. e certidões a fls. 83/87 e 231/232), a pena base não merece exasperação vez que o acusado se manteve inerente aos moldes do tipo penal em espécie, nos exatos termos do artigo 42 da lei 11.343/06. Assim, fixo a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa. Fixo o valor do dia-multa no mínimo legal, ante a falta de elementos sobre a real situação econômica do réu (CP, arts. 49 e 60). Na segunda fase, embora presente a agravante da reincidência (fls. 231/232), o réu acabou por confessar a prática delitiva. Assim, faço a compensação e mantenho a pena no patamar anterior fixado, nos termos da Súmula/STJ, nº 545: "Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal". Não estão presentes outras agravantes ou atenuantes. Por fim, na terceira fase, entendo que inexistem causas de aumento ou de diminuição da pena. Não incide a benesse prevista no §4º do artigo 33 da Lei de Drogas, pois o réu não preenche todos os predicados legalmente previstos, pois, além da reincidência (fls. 231/232), a quantidade e variedade da droga apreendida aliado ao fato de que transportou a pedido de terceira pessoa revelam que se dedica à atividade criminosa. Nesse sentido: "Não há ilegalidade na negativa de aplicação da causa especial de diminuição prevista no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, porquanto a quantidade e a natureza da substância apreendida levaram à conclusão de que o paciente se dedica a atividades delituosas, ou seja, não se trata de traficante ocasional" (HC 297447/RS, Ministro JORGE MUSSI, DJe 13/11/2014). E nem se alegue possível bis in idem relativo ao aumento da pena pela reincidência e a não aplicação do aludido redutor, uma vez que este deixou de incidir também em virtude da dedicação às práticas delitivas, tudo em fases distintas da dosimetria. Confira-se: "A valoração da reincidência na segunda etapa da dosimetria, como circunstância agravante, não é incompatível com a sua utilização, na terceira fase, para afastar a incidência da causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, porquanto o referido instituto jurídico é sopesado com finalidades distintas em cada fase de fixação da pena, justamente para se alcançar a justa e correta reprimenda necessária para a reprovação e prevenção do delito perpetrado. Precedentes" (HC 214069/SP - Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ - Sexta Turma - DJe 29/11/2013). Desta forma, fixo em definitivo a pena a cumprir de 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA COM O DIA UNITÁRIO NO PISO MÍNIMO LEGAL.

Diante do disposto no artigo 2º, parágrafo 1º da Lei nº 8.072/90, os réus Elcio Benedito e João de Oliveira deverão iniciar o cumprimento da pena em regime FECHADO. O restante da pena e eventuais benefícios legais deverão ser objeto de análise do juízo das execuções. É importante não perder de vista que a consideração do tempo de prisão provisória do réu não altera o panorama do regime inicial da pena aplicada. Assim, deixo de aplicar o disposto no § 2º do art. 387 do Código de Processo Penal, pois como bem indica Guilherme de Souza Nucci, "O disposto no §2º do artigo 387 do Código de Processo Penal, permite que o julgador promova o desconto pertinente à detração ao escolher o regime inicial do réu no caso de condenação. Não significa de modo algum que o magistrado deve sempre conceder o regime inicial mais brando, pois se pode considerar como adequado regime inicial mais gravoso, nos termos do art. 59 do Código Penal, indicado pelo art. 33, § 3º. Afinal, somente o juiz da execução penal possui o quadro completo das condenações daquele réu, do seu comportamento carcerário, e do seu merecimento" ("Código de Processo Penal Comentado", 13ª edição, Editora Forense, páginas 805 e 806). Desta forma, melhor que a questão seja analisada pelo Juízo de Execuções Criminais, que certamente disporá de elementos mais substanciais para decidi-la.

Inviável a substituição por pena restritiva de direitos, seja pelo fato de estarem ausentes os requisitos previstos nos artigos 44, III, e 77, II, ambos do Código Penal, seja porque o art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90 estabelece que a reprimenda por crime de tráfico de drogas deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado, seja, finalmente, porque o art. 44, caput, da Lei nº 11.343/2006, são expressos ao proibir referido benefício. Filio-me ao entendimento que sustenta a

constitucionalidade de tais dispositivos, pelas seguintes razões, algumas delas retiradas da Arguição de Inconstitucionalidade no HC 120.353-SP, julgada em 04.11.2009 pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, Rel. originário Min. Og Fernandes, Rel. para acórdão Min. Ari Pargendler: i) o art. 5º, inciso XLVI, da CF/88, determina que a lei regulará a individualização da pena; ii) o art. 5º, inciso XLIII, da CF/88, estabelece que a lei deverá dispensar tratamento mais gravoso ao crime em questão, destacando também a importância da repressão a esse delito no art. 5º, inciso LI, o qual autoriza a extradição de brasileiro naturalizado comprovadamente envolvido com tráfico de drogas; iii) é perfeitamente possível que o legislador ordinário proíba a substituição da pena por restritiva de direitos, tanto que o art. 44, do CP, veda o benefício para todos os crimes praticados mediante violência ou grave ameaça à pessoa ou com pena superior a 04 anos, ou, ainda, no caso de ser o agente reincidente em crime doloso; iv) o Brasil assinou tratados internacionais se comprometendo a combater o tráfico de drogas; v) o crime de tráfico de drogas, além de ser equiparado a hediondo e ser a principal causa de inúmeros outros delitos patrimoniais, gera efeitos nefastos para a sociedade e para as famílias de bem, de modo que a concessão do benefício, além de ser, no meu entender, incompatível com a sua gravidade, não se mostraria suficiente para a prevenção ou reprovação do delito (CP, art. 59, in fine), gerando ofensa ao disposto no art. 44, III, do CP, além de verdadeira sensação de impunidade nesta pequena e interiorana cidade de Avaré.

Deixo de reconhecer o direito dos réus Elcio Benedito e João de Oliveira de apela-rem em liberdade, em observância ao artigo 312 do CPP c.c. artigo 2º, § 3º da Lei nº 8.072/90, pois a gravidade do delito, que vem se alastrando de forma avassaladora também nas pequenas cidades, torna evidente a necessidade da prisão para se garantir a ordem pública. Outrossim, porque os réus responderam presos ao processo, de sorte que seria um paradoxo colocá-los em liberdade exatamente depois de receberem sentença condenatória. Recomendem-se.

Diversamente, diante da absolvição do réu Bruno José Ribeiro Barbosa, expeça-se, com urgência, alvará de soltura.

Conforme art. 63 da Lei nº 11.343/06 c/c art. 91 do CP, decreto o perdimento de tudo quanto apreendido neste processo. Não tendo havido controvérsia, no curso do processo, sobre a natureza e a quantidade da substância entorpecente ou sobre a regularidade do laudo respectivo, fica determinado, desde já, sua destruição por incineração, na forma da legislação vigente (Lei n. 11.343/06, arts. 33, §§ 1º e 2º, e 58, §1º), no prazo máximo de 30 (trinta) dias, preservando-se fração suficiente para eventual contraprova. Comunique-se à autoridade de polícia judiciária competente, caso isso ainda não tenha sido providenciado.

Registre-se, desde logo, que, em caso de recebimento de eventual recurso de apelação interposto contra a presente, deverá ser expedida a competente guia de execução provisória em nome dos réus/condenados recorrentes, nos termos do que dispõe o art. 9 da Resolução nº 113/2010 – CNJ, para que possa, quando for o caso, obter os benefícios previstos na LEP (sumula do STF, Enunciado nº 716).

Oportunamente, após o trânsito em julgado da presente, adotem-se as seguintes providências: (a) expeça-se guia de execução (definitiva, se o caso) dos condenados; (b) proceda-se ao recolhimento do valor atribuído a título de pena pecuniária, em conformidade com o disposto no artigo 686, do Código de Processo Penal; (c) oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando as condenações, com as devidas identificações, acompanhada de fotocópia desta decisão, para cumprimento do disposto no art. 15, III, da Constituição da República c/c o art. 71, §2º, do Código Eleitoral; (d) oficie-se ao órgão responsável pelo cadastro de antecedentes criminais deste Estado para as anotações necessárias; (e) efetuem-se as averbações de praxe (NSCGJ, Cap. V, itens 22, d, e 23). Custas processuais nos termos da lei.

P.I.C.

Avare, 26 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA